

1501244-02.2021.8.26.0438

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Victor Alvares Gonçalves

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... revelam que a droga destinava-se ao tráfico.

Aliás, tal conduta é comum entre pequenos traficantes, que traficam justamente para sustentar o vício.

Assim, considerando a prova produzida, tenho que a condenação é medida que se impõe, sendo de rigor a condenação do réu pela prática do tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo".

Por outro lado, verifico que o réu é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

2ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis - SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501244-02.2021.8.26.0438 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501244-02.2021.8.26.0438

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Victor Alvares Gonçalves

Vistos.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em face de MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo consta da denúncia, no dia 14 de julho de 2021, por volta das 23h50, na Rua Luiz Eduardo Nadai Alberton, n. 750, Santa Casa, nesta cidade e comarca de Penápolis, o acusado trazia consigo para o consumo de terceiros 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, sendo 38 delas na forma de crack, pesando respectivamente 1,47 grama e 11,68 gramas.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 01), tendo sido decretada sua prisão preventiva (fls. 58/59).

A denúncia foi recebida no dia 04 de agosto de 2021 (fls. 89/90).

Devidamente citado (fls. 112), o réu apresentou defesa prévia através de advogado nomeado pugnando pela concessão de liberdade provisória (fls. 130/134).

Na instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas. Ao final foi interrogado o

acusado.

Em memoriais escritos o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (fls. 176/184). Já a defesa pugnou pela absolvição. Subsidiariamente requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, com a fixação da pena no mínimo legal (fls. 198/202).

É, em síntese, o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade do crime de tráfico de drogas é positiva, tal como se extrai do auto de prisão em flagrante de fls. 01, do Boletim de Ocorrência de fls. 02/04, do auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, bem como dos laudos de constatação provisória de drogas de fls. 24/25 e 26/27 e também dos exames toxicológicos definitivos de droga de fls. 104/106 e 107/108 os quais identificaram 44 (quarenta e quatro) porções de cocaína, sendo 38 delas na forma de crack, pesando respectivamente 1,47 grama e 11,68 gramas.

A autoria do crime também é certa e restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo BO de fls. 02/04, bem como pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, como também em juízo.

Em juízo, confirmando seu depoimento administrativo, a testemunha Juliano Ferreira Lopes disse que estava acabando de apresentar uma ocorrência pelo plantão quando por volta das 23h30, pessoa que não quis se identificar, disse que na casa do Nei, bairro da Pevi, com um agasalho de cor preta, tinha uma pessoa fazendo tráfico de drogas lá. Chegando lá depararam-se com o Manoel sentado na frente da casa. O réu saiu correndo mas já veio a ser detido com o uso de força necessária. No bolso do moletom encontrou a quantidade de 38 pedras de crack, cinquenta reais e um aparelho celular. O réu negou que estaria traficando. Negou a propriedade da droga. Apenas falou que a droga não lhe pertencia. O réu já era conhecido dos meios policiais pelo tráfico de drogas. Só tinha ele no momento dos fatos. Foram direto para o DP, não passaram na casa de Igor. Iguinho é outro traficante do bairro.

No mesmo sentido, a testemunha Murilo Moreira Alberton disse que no dia dos fatos estava o Manoel na frente da casa do Nei. Encontraram Manoel na frente da casa, ele estava sozinho. Não levaram Manoel para a casa de Igor. Seu parceiro localizou a droga no bolso da blusa. No momento que viraram a viatura e pararam a viatura ele já levantou e tentou se evadir. Ele foi contido. O réu negou a propriedade da droga. O réu disse que estava vendendo a droga para alguém. Ele confirmou que estava vendendo.

Na fase administrativa o réu disse que "Não estou assistido por advogado e requeiro a nomeação de Defensor Público para me defender durante os atos processuais. Minha prisão foi comunicada para minha amiga Regiane (18 991694577) e para meu tio (fone 11 963215614). As algemas apertaram meus braços e não resisti à prisão. Sobre os fatos, declaro que estou ficando na casa dos meus amigos Jomar e Regiane, que foram cientificados sobre minha prisão. Por volta das 23h40, saí de casa para comprar cigarro na conveniência, que fica perto da casa que estou, que não sei dizer o endereço. Comprei o cigarro e um corote de pinga e fiquei bebendo com o Nei, na frente da casa dele, quando os Policiais chegaram e me abordaram. No momento da abordagem eu estava com o Nei. Os Policiais me colocaram sentado. Eu não estava com drogas, não sabia da existência de drogas, contudo, visualizei quando os Policiais acharam as drogas no chão, na frente da casa do Igor, vulgo Iguinho. Acredito que as drogas estavam escondidas a cerca de 300 metros de onde eu fui abordado. As drogas não eram minhas. Acho que as drogas eram do Igor, uma vez que o visualizei diversas vezes mexendo no local onde as drogas foram encontradas. O dinheiro apresentado, quem somam R\$ 50,00, e o telefone celular são meus e provenientes do meu trabalho na roça. Autorizei o acesso ao meu telefone celular, inclusive forneci a senha e o deixei desbloqueado, pois não há nada que possa me comprometer. Igor vestia uma camiseta vermelha e estava acompanhado de outra pessoa" (fls. 07).

Em juiz o réu disse que a acusação não aconteceu. Não conhece ninguém dentro da cidade. Mal conhece a cidade. Veio de fora. Seu irmão é encarregado da roça, veio

da Bahia para trabalhar no meio de 2020. Seu irmão faleceu na roça e acabou ficando sozinho. Não tem envolvimento com tráfico. Lembra que ficou preso, depois saiu, ficou umas três semanas, duas semanas, por aí. Assumiu a casa que morava com seu irmão. Estava registrado até o ano passado. Ficou na rua, estava sem lugar para ficar. Saiu da prisão e foi para a casa de seu patrão da roça. Foi para resolver as coisas da casa que morava, aí um rapaz que morava na frente de onde foi abordado, que conheceu na roça. O rapaz pediu para ajudar para tirar os móveis da casa. O depoente tirou os móveis, ficou alguns móveis lá. O rapaz chamou para o depoente dormir lá. Ficou por ali sentado. Também é viciado em crack também. O Nei é o dono da casa estava lá, ele teve seus vícios. Estava usando lá. Estavam fumando mesclado lá na frente. Abordaram o depoente ali, falou que estava de provisória. Esse rapaz chamado como Iguinho mora na rua, uns trezentos, quatrocentos metros, do local onde eles traficam. O depoente falou que a droga não era sua. Esse Iguinho que estava trazendo droga. Iguinho se deparou com a viatura vindo, voltou correndo. Iguinho dispensou algumas porções. A polícia achou as porções. Uma porção estava com o depoente, o resto não estava. Iam comprar mais de Iguinho. Pois bem.

Os policiais militares que realizaram a abordagem, desde a fase administrativa, de forma uníssona, disseram que todas as drogas foram encontradas na posse do acusado. Na fase administrativa o réu disse que desconhecia qualquer droga. Já em juízo mudou sua versão dizendo que realmente estava com algumas porções de entorpecentes, mas que eram para seu uso, que estava usando no momento da abordagem. A alteração de versões por parte do acusado demonstra que sua versão não é digna de crédito. Por outro lado, nada veio nos autos a infirmar a credibilidade dos relatos policiais.

Ainda que o réu também possa ser usuário fato é que a quantidade relevante de porções, de duas espécies, portadas em via pública, revelam que a droga destinava-se ao tráfico.

Aliás, tal conduta é comum entre pequenos traficantes, que traficam justamente para sustentar o vício.

Assim, considerando a prova produzida, tenho que a condenação é medida que se impõe, sendo de rigor a condenação do réu pela prática do tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo".

Por outro lado, verifico que o réu é tecnicamente primário, não possuindo maus antecedentes. Também não há comprovação de que se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. A recente condenação por tráfico de drogas não pode ser valorada, posto que ainda não houve o trânsito em julgado. Sendo assim, de rigor a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, no máximo legal.

Passo à dosimetria da pena.

Antes de iniciar a fixação da pena-base, esclareço que, nesta primeira fase da dosimetria, a pena sempre partirá do mínimo previsto em lei e, a cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a pena mínima será acrescida da fração de 1/10 (um décimo) calculada sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstrata prevista para o crime em questão.

A fração a ser aplicada é de 1/10 (um décimo) justamente porque são oito as circunstâncias judiciais a serem valoradas por força do art. 59 do CP, mais duas previstas no art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da droga).

Com isso prestigia-se a proporcionalidade na aplicação das penas, uma vez que se respeita a gravidade do delito, reconhecida pelo legislador, quando da fixação da pena máxima.

Utilizando-se este procedimento, crimes que possuem a mesma pena mínima, mas diferentes penas máximas, justamente por serem de gravidade distinta, serão apenados adequadamente, cada um com sua gravidade e grau de censura já estipulados em lei.

Não é razoável que para crimes de diferente gravidade, a exasperação da pena-base parta do mesmo patamar mínimo, ignorando-se a pena máxima imposta pelo legislador. Sendo assim, como regra, este será o critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, até para prestigiar o entendimento que vem sendo fixado no

âmbito do STJ, conforme se extrai das decisões exaradas no HC 218.249/SP, julgado em 13/09/2016, e no HC 285.490/PE, julgado em 06/10/2016.

Por fim, ressalto que, diante de casos concretos excepcionais, e mediante fundamentação exaustiva, as frações de cálculo poderão ser diminuídas ou aumentadas de forma diversa, para que se possa individualizar adequadamente a pena, até a fim de prestigiar a preponderância da natureza e da quantidade de drogas em relação às demais circunstâncias, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

Isso posto, passo à análise das circunstâncias judiciais.

O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas prevê pena de reclusão de 05 a 15 anos e de 500 a 1500 dias-multa.

Em relação à quantidade da droga apreendida nada a valorar. A natureza da droga merece valoração negativa, já que houve a apreensão de cocaína, droga de alto poder viciante, extremamente maléfica à saúde humana. A culpabilidade é normal à espécie. O réu não possui maus antecedentes. Quanto à conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos suficientes para adequada avaliação. O motivo do delito é normal à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. No que pertine às consequências, certo é que não restaram caracterizadas outras consequências além daquelas próprias do tipo penal. Finalmente, não há que se valorar o comportamento da vítima, pois se trata de crime vago, em que a vítima é a sociedade como um todo. Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausente qualquer agravante ou atenuante, razão pela qual mantenho a pena-base.

Ausente qualquer causa de aumento de pena. Presente a minorante prevista no art.

33, §4º, da Lei de Drogas, tal como já fundamentado acima, razão pela qual diminuo a pena em 2/3 (dois terços), fixando a pena final em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Considerando a situação econômica do acusado, o dia-multa será calculado a base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo na data do fato, atualizado pelos índices de correção monetária (§§ 1º e 2º, do art. 49 do CPB).

Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, adoto o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, que previa necessariamente o regime inicial fechado para os crimes hediondos.

Ademais, no HC 118.533, recentemente o STF firmou o entendimento de que o tráfico "privilegiado" do art. 33, §4º, da Lei de Drogas não é crime hediondo.

Sendo assim, nos termos do art. 33, §3º e 59, ambos do CP, tendo em vista a pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO (ART. 33, do CP).

Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada à ré por duas restritivas de direito, a saber: prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma do art. 46, CP - à razão de uma hora por dia de condenação, nos termos a serem definidos pelo juiz da execução.

Diante da pena aplicada a segregação cautelar mostra-se desproporcional. Sendo assim concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para o fim CONDENAR o réu MANOEL MESSIAS DOS SANTOS, pela prática do delito de tráfico "privilegiado" de drogas (art. 33, caput, c/c art. 33, §4º, ambos da Lei de Drogas), e, por consequência, às penas 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO, sendo cada dia-multa arbitrado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, a ser prestada em entidade a ser indicada pelo juízo da execução.

O réu poderá recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado imediatamente.

Disposições finais:

- a) Determino a incineração da droga apreendida, caso tal medida ainda não tenha sido tomada pela autoridade policial;
- b) Decreto o perdimento do dinheiro em favor da União, nos termos dos arts. 63, §1º, e 64 e da Lei de Drogas;
- c) Determino a devolução do celular ao acusado, posto que não houve comprovação de que o utilizava com o intuito de traficância;

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804, CPP). Concedo a gratuidade da justiça ao réu, diante da situação financeira apresentada, de modo que a exigibilidade das custas fica suspensa (art. 98, §3º, CPC).

Expeça-se certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio OAB/DPE.

Após o trânsito em julgado: a) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do art. 15, inciso III, da CF/88; b) Calcule-se a multa, intimando-se para pagamento; c)

Expeça-se guia de recolhimento definitiva; d) Oficie-se ao Instituto de

Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD).

Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se.

Penápolis, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA